

1500677-46.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º DA LEI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guaçu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500677-46.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500677-46.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097932/2022 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 24198301 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2097932 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE ALVES DE LIMA - Matrícula SAP 362687-6

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

JOSE ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 09 de abril de 2022, na madrugada, no endereço descrito com a inicial, o denunciado trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 01 pedra de crack, 05 pinos de cocaína e 12 porções de maconha, mais R\$ 7,00 em dinheiro, em desacordo com determinação legal.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais durante a audiência.
DECIDO.

Inicialmente, não conheço da preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, em razão da ausência de fato novo, ficando reafirmados os mesmos fundamentos trazidos às fls. 162.

No mérito, cumpre reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 13/14), pelo laudo toxicológico (fls. 147/149) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal do réu, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É certo que o réu, na fase judicial, negou o ocorrido, aduzindo, em síntese, que estava no local, no dia dos fatos, para comprar drogas, sendo que o traficante, em troca de duas pedras de crack, acabou por lhe deixar a sacola, até que fizesse o reabastecimento, momento em que foi abordado pela GCM.

Contudo, as suas alegações não encontram amparo na prova oral colhida nos autos, que foi firme e segura em confirmar todo o desenrolar fático apontado pela denúncia.

Nesse sentido, o guarda municipal WALTER DE ALMEIDA, na fase judicial, disse que avistou o denunciado em atitude suspeita, já que o acusado acelerou os passos, oportunidade em que efetuou a abordagem, localizando com o denunciado uma sacola, contendo drogas e um papel com anotações.

Da mesma forma, as declarações do guarda municipal MARCELO na fase judicial, sendo certo que, na fase policial, os guardas descreveram a mesma dinâmica (fls. 05/06).

Não há provas que tenham o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato praticado pelos guardas municipais, de modo a indicar que a diligência policial foi perpetrada em função de interesses escusos.

Realmente, não se nega que, por vezes, haja desvios de finalidade na prática de atos administrativos, infelizmente, movidos por interesses que não se compatibilizam com as funções precípuas do Estado, mas não parece ser o caso dos autos.

É que não seria razoável que os guardas municipais tivessem apreendido drogas, mais dinheiro e falsamente imputassem a indivíduo que sequer tinham qualquer rixa ou desentendimento.

Em acréscimo, cabe salientar que o exame de corpo de delito não apontou qualquer lesão relacionada às diligências, tendo consignado que o réu estava com uma queimadura (fls. 76).

Assim, a diligência enquadra-se na grande maioria dos atos administrativos, ou seja, daqueles realizados de forma legítima e segundo os ditames da boa-fé.

Em acréscimo, mister salientar que não há qualquer ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso dos autos, porquanto os informes foram no sentido de que a guarnição estava em patrulhamento de rotina, quando se depararam com a situação de flagrante.

Cuidando-se de situação de flagrante delito, a atuação da Guarda Municipal revelar-se-ia cabível, diante do teor do artigo 301 do Código de Processo Penal.

A este respeito, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.

POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; entretanto, em situações de flagrante delito, a atuação desses agentes está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 675.507/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).”

Em arremate, não se afigura possível acolher a tese da Defesa técnica, que pontuou, basicamente, duas questões: a) a quantidade de drogas encontradas não é compatível com a quantidade de dinheiro encontrado, a afastar a tese da intenção de traficar; b) o réu, além de ser usuário de drogas, permaneceu pouco tempo com a sacola, tendo indicado o nome do traficante, a tornar impassível a conduta como tráfico de drogas.

Ora bem, a figura típica imputada com a inicial acusatória é de trazer consigo drogas, não vender entorpecentes, e, assim sendo, não há margem para realizar o raciocínio proposto pela Defesa e apontado no item “a”, cabendo considerar, ainda, que pesa em desfavor do réu o fato de a anotação acostada às fls. 31 não permitir extrair o nome do mencionado traficante Toninho, enfraquecendo, sobremaneira, a tese de que estava apenas segurando a sacola para terceira pessoa.

Na verdade, a conduta de permanecer com a sacola, em troca de entorpecentes, em razão da necessidade de mero dolo genérico para a configuração do tipo penal do tráfico de drogas, por si só, já seria conduta passível de enquadramento da conduta do denunciado, inclusive, no mesmo verbo mencionado na denúncia, já que os guardas municipais informaram que o réu movimentou-se com os entorpecentes.

Por conseguinte, insubsistentes as alegações constantes do item “b”.

Acerca da questão do consumo diário do denunciado, deve-se destacar que se trata de informação trazida apenas e tão somente pelo réu, sem qualquer amparo, ao menos, em declarações de outras testemunhas, impassível de se constituir em premissa verdadeira, a subsidiar a linha de raciocínio da Defesa técnica de que o réu seria inapto a atuar para o tráfico de drogas, em razão de seu alto consumo de drogas.

Neste panorama, é indiscutível a veracidade dos fatos articulados na denúncia, constituindo a conduta afronta ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, eis que presentes a autoria, a materialidade, o dolo e a tipicidade da conduta, não havendo, por conseguinte, margem sequer para o acolhimento da tese de desclassificação para o crime de porte ilegal de drogas.

Portanto, passo a dosar a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1/6 acima do mínimo legal.

Justifica-se a exasperação, em razão dos maus antecedentes do réu, que foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 26564-90/2005 e do Processo n.º 683-79/2009 (fls. 58).

Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase de aplicação da pena, majoro a reprimenda em 1/6, eis que o crime foi praticado nas proximidades de escola, consoante afirmaram ambos os guardas municipais, totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

No mais, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, eis que a aplicação do dispositivo demanda o preenchimento cumulativo de seus requisitos, desde que associados às circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas.

No presente caso, o réu trazia consigo drogas dos mais diversos tipos para entrega a terceiros, sendo que esta peculiaridade, aliada à anotação com a contabilidade do tráfico de drogas (fls. 31), permitem a conclusão de que não se trata de traficante não habitual.

A reforçar esse entendimento, não se pode desconsiderar que existem informações nos autos, a partir dos informes dos guardas municipais e do próprio interrogatório judicial do réu, de que o local era ponto de venda de drogas.

Em acréscimo, cabe destacar que o réu sofreu condenação, com trânsito em julgado, pelo crime de furto e, principalmente, tráfico de drogas, elementos a mais, a indicar que tinha propensão a atividades criminosas.

Sobre os maus antecedentes criminais como motivação idônea para a negativa à aplicação da causa de diminuição, confira-se o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que a análise anterior das matérias objeto do recurso especial nos autos de habeas corpus impetrado com idênticos fundamentos e pedidos implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão recursal. Precedentes.

3. Na espécie, os pleitos atinentes à desproporcionalidade do quantum incrementado à pena-base e ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena foram anteriormente apreciados por este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 672.615/SP, impetrado pela mesma parte, contra o mesmo acórdão, sob os mesmos fundamentos e com os mesmos pedidos. Assim, inafastável o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial, nos pontos.

4. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

5. In casu, consoante asseverado pelas instâncias ordinárias, o recorrente ostenta múltiplas condenações anteriores, também por tráfico de drogas, configuradoras de

maus antecedentes (e-STJ fls. 465 e 609) - o que, por si só, constitui fundamentação idônea para afastar a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 -, além de ter sido preso em flagrante delito por transportar e guardar, para fins de tráfico, 163,480kg de cocaína (e-STJ fl. 602). Nesse contexto, inviável a aplicação da privilegiadora postulada.

6. Agravo regimental não provido. (grifo nosso).

(AgRg no REsp 1970177/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)."

Portanto, sob todos os ângulos analisados, o réu não faz jus à causa de diminuição.

Sendo assim, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente, a contar da mesma data.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando as provas de que se dedicava a atividades criminosas, de modo que a imposição de regime menos rigoroso não surtirá qualquer efeito.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado, consoante aresto que passo a transcrever:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Corte de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.
 2. As peculiaridades do caso concreto (quantidade e natureza da droga, bem como a dedicação do acusado ao narcotráfico) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.
 3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
 4. Agravo regimental não provido.
- (AgRg no HC 566.498/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)."

Não havendo qualquer influência o tempo de pena provisória cumprida, para fins de detração penal, porquanto ofensiva ao princípio do juiz natural e da individualização da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Não se nega que, em função da cautelaridade da prisão provisória, o pedido deve ser juridicamente possível, ou seja, não deve encontrar obstáculo em qualquer das vedações legais previstas na Lei n.º 12.403/11.

Contudo, no caso em exame, houve decreto de prisão preventiva (fls. 66/68), que esteve a considerar todas estas circunstâncias legais e fáticas, em decisão não impugnada pela Defesa.

E, neste meio tempo, nada houve que tivesse o condão de apontar a existência de fatos novos, inclusive jurídicos, senão aqueles que subsidiaram a r. decisão lançada.

Sendo assim, ainda mais agora que todo o contexto probatório está a indicar ter

sido o réu autor do delito, nada há que esteja a justificar nova apreciação do pedido, sob pena de, por via transversa, desfazer-se situação jurídica consolidada e suprimir instância judicial.

Assim, sob todos os ângulos analisados, não há qualquer constrangimento ilegal que esteja sendo imposto à liberdade de locomoção do réu, sendo de rigor a manutenção da medida.

Ante o exposto, CONDENO JOSE ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

DECRETO a perda, em favor do Estado de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA